

1502657-65.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -

cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502657-65.2021.8.26.0530

Controle: 2021/002524

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316071/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR COUTINHO DE ALMEIDA

Aos 22 dias do mês de agosto de 2022, às 13:30 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; o réu João Vítor Coutinho de Almeida, sua Defensora nomeada, Dra. EVELYN MIESSA DOS SANTOS DINAMARCO (OAB/SP 333739); COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas pela acusação Guardas Civis Municipais Alefer Douglas Cosenza e Gabriel Valério de Azevedo. À defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes de seu interrogatório, em sala virtual. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação Guardas Civis Municipais Alefer Douglas Cosenza e Gabriel Valério de Azevedo, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz

interrogou o réu João Vítor Coutinho de Almeida, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

Vistos.

JOÃO VITOR COUTINHO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 12h25min, na rua Joaquim Lucas da Silva nº 344, Conjunto Habitacional Vila Áurea Mendez Gimenez, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 10 (dez) cápsulas do tipo eppendorff contendo Cocaína, bem como guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 21 (vinte e uma) cápsulas do tipo eppendorff contendo Cocaína, substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, guardas civis municipais realizavam um patrulhamento de rotina no local supracitado quando notaram que o acusado empreendeu fuga assim que os avistou. O acusado foi abordado, e, em suas mãos, foram encontradas 10 (dez) cápsulas de Cocaína. No bolso de sua bermuda, foi localizada a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais). Ato contínuo, os guardas retornaram ao local em que o réu inicialmente estava, e, na tampa de um bueiro, apreenderam um saquinho contendo outras 21 (vinte e uma) cápsulas de Cocaína. Todos os entorpecentes pesaram 24,59g (vinte e quatro gramas e cinquenta e nove decigramas). O réu admitiu a autoria delitiva, dizendo que havia recebido um kit contendo 13 (treze) cápsulas de Cocaína, as quais iria vender. Ele foi preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 77/78), o réu foi citado (fls. 84) e apresentou defesa prévia (fls. 89/91).

Durante a instrução, foram ouvidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado em seguida.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação de penas mínimas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 20/21), pelas imagens fotográficas (fls. 26 e 27), pelo exame químico-toxicológico (fls. 67/69), conclusivo por se tratar de Cocaína, e pela prova oral colhida.

A autoria também é indubitável.

Os guardas civis municipais Alefer e Gabriel, tanto na fase policial quanto em Juízo, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o réu parado em uma esquina. Narraram que o réu fugiu assim que viu a viatura, mas foi detido em outra rua, logo depois. Após abordado, foi encontrado na mão do réu, 10 (dez) eppendorfs de Cocaína, além da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais), no bolso da bermuda que o réu vestia. Retornaram ao local onde estava inicialmente o acusado, e encontraram um saquinho escondido em um bueiro contendo 21 (vinte e um) eppendorfs de Cocaína. Em conversa com o réu, ele disse que estava morando na rua e estava vendendo drogas para ganhar dinheiro, sendo que todas as drogas apreendidas eram deles. Relataram ainda que o réu foi abordado na manhã, mas que estava apenas com dinheiro, sem material ilícito, motivo pelo qual não foi

detido. Em Juízo, ratificaram o relato inicial acrescentando que o réu fugiu por cerca de 80 metros, até ser detido, bem como que admitiu que realmente praticava o tráfico no local, e inclusive foi preso em flagrante posteriormente, por fato análogo (fls. 05, 06 e mídia).

O réu, interrogado na fase policial, alegou que estava morando na rua e que na data dos fatos, havia recebido um "kit drogas" para vender, contendo 13 (treze) eppendorfs de Cocaína. Disse que desconhece a pessoa que lhe forneceu o kit. Alegou que desconhece, também, o restante das drogas encontradas pelos guardas civis municipais (fls. 07).

Em Juízo, negou a acusação. Alega que estava morando na rua e pedindo comida, quando um rapaz, chamado Armando, pediu que comprasse droga para ele e, em contrapartida, daria um prato comida para o interrogando e 2 pinos de cocaína. Armando deu R\$ 35,00 ao interrogado. Assim que comprou os 13 pinos do traficante, os guardas se aproximaram e foi detido. Os traficantes fugiram. Estava também na posse de R\$ 5,00, que era de sua propriedade. Nega que estava na posse ou fosse o proprietário dos outros 21 pinos de cocaína, alegando que somente tomou conhecimento deles na Delegacia. Encontra-se atualmente preso por nova acusação de tráfico de drogas, tendo sido preso pelos mesmos guardas, que o perseguiram (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o artigo 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas guardas municipais, em patrulhamento pelo local dos fatos, o réu agiu de forma suspeita, pois empreendeu fuga assim que viu a viatura, motivo pelo qual foi perseguido e contido. Em revista pessoal, encontraram na posse do réu 10 (dez) cápsulas do tipo eppendorf contendo Cocaína e R\$ 5,00 em dinheiro, e depois retornaram aonde ele estava inicialmente, e encontraram um saquinho contendo 21 (vinte e uma) cápsulas do tipo eppendorf contendo Cocaína, escondidos num bueiro.

Ademais, o réu confessou aos guardas e depois quando interrogado na fase policial que realmente estava realizando a mercancia das drogas apreendidas, pois morava na rua e estava precisando de dinheiro. Disse que recebeu um "kit drogas" contendo 13 (treze) eppendorfs de Cocaína.

Tal confissão, ademais, não pode ser desprezada, notadamente por ser coerente e compatível com as demais provas produzidas nos autos. Não bastasse, caberia ao acusado demonstrar que a confissão perante a autoridade policial foi obtida por meio ilícito, porque ser presumível que a autoridade policial age no estrito cumprimento do dever legal.

No mais, a credibilidade dos depoimentos dos guardas ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que os tivessem a intenção de prejudicar a acusada. Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Destaco ainda que a nova versão do acusado, de que apenas foi comprar para um terceiro a droga apreendida em sua posse, e que os traficantes correram com a aproximação da viatura, não encontra amparo em qualquer outra prova dos autos, não devendo, portanto, prevalecer.

Assim, considerando que o réu tentou fugir da viatura, foi abordado na posse e ainda escondendo significativa quantidade de droga e dinheiro, confessou a acusação seja perante os guardas e também perante a Autoridade Policial, bem como deixou de comprovar a prática de qualquer atividade remunerada lícita, conclui-se que a droga apreendida realmente era do réu e se destinava ao tráfico.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é confesso, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

“O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada.” (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminoso, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização

da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma suprallegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é

suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime. Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela destruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOÃO VITOR COUTINHO DE ALMEIDA, qualificada nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06. Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pelo Réu e sua Dra. Defensora foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: “Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. Arbitro honorários advocatícios à Defensora nomeada Dra. Jéssica de Lima Zanandréa (OAB/SP 405956) em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais.” Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.